

1004306-90.2022.8.26.0400

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Defeito, nulidade ou anulação

Magistrado: Angelo Marcio de Siqueira Pace

Comarca: Olímpia

Foro: Foro de Olímpia

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... e materiais - autora que comunicou o furto de seu aparelho celular à autoridade policial - banco requerido que não comprovou que a transferência bancária realizada horas após do furto tenha sido efetuada mediante uso de senha informada pela autora - ausência de prova de que o aplicativo de celular seja guarnecido com meios de assegurar a identidade de quem tenta realizar ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Olímpia

Foro de Olímpia

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua São João, 865, Olímpia - SP - cep 15400-000

1004306-90.2022.8.26.0400 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1004306-90.2022.8.26.0400

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação

Requerente:

Luciana Aparecida Costa da Cruz

Requerido:

Nu Pagamentos S/A - Nubank

Controle: 2022/001585

Juiz de Direito: Angelo Marcio de Siqueira Pace

Vistos.

I. Dispensado o relatório (art. 38, da Lei nº 9.099/95).

FUNDAMENTO e DECIDO.

II. Procedo ao julgamento antecipado (Art. 355, inciso I, do CPC).

Não há preliminares.

No mérito, o pedido é procedente em parte.

Conforme a narrativa, no dia 21/08/2022, a autora teve seu celular (chip nº (17) 99175-9680) furtado na "Festa do Peão de Barretos". Após a subtração do aparelho, a requerente notou que seu aplicativo bancário havia sido acessado e realizadas operações financeiras (pagamento de boleto e contratação de empréstimo). O pedido inicial é para que o réu deixe de efetuar os descontos das parcelas do empréstimo disponibilizado mediante fraude, devolva, em dobro, a quantia do boleto pago, além de indenização por dano moral.

O requerido, em sua defesa, sustenta que a transação impugnada foi feita por meio de um dispositivo autorizado pela demandante e com a utilização de senha pessoal. Defende que não houve falha na prestação de seus serviços, uma vez que foi comunicado sobre o furto somente após as transações impugnadas, e atribui à autora a culpa pela situação descrita na inicial. Pede a declaração de improcedência das pretensões autorais.

Pois bem.

Trata-se o presente caso de típica relação de consumo, sendo aplicáveis as regras contidas no Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova, inclusive.

Deste modo, cabia ao banco réu trazer aos autos prova segura de que as transações realizadas na conta da autora ocorreram de forma legal e regular, ou, ainda, demonstrar que ela, de fato, forneceu suas credenciais e dados bancários a terceiros estranhos - o que não aconteceu.

Por outro lado, a autora juntou, às fls. 18/25, documentos que comprovam a contratação do empréstimo em seu nome na mesma data do furto do celular (valor de R\$ 6.128,75, valor liberado de R\$ 6.000,00, em 12 vezes de R\$ 642,83 cada parcela, perfazendo um valor total de R\$ 7.713,96, com taxas e juros (contrato: 0131605778419156965430712881904184572788)). Trouxe aos autos, ainda, comprovante de pagamento de um boleto, também no dia 21/08/2022, no valor de R\$ 2500,00, no qual constava com favorecido RECARGAPAY DO BRASIL SERVICOS DE INFORMÁTICA, Banco do Brasil S.A.

Às fls. 13/17, a requerente juntou cópia do Boletim de Ocorrência registrado perante a autoridade policial (nº FJ 2520-2/2022) e, às fls. 27/28, a contestação administrativa das movimentações bancárias ocorridas em sua conta, o que corrobora a alegação de que as transações foram realizadas sem o seu conhecimento e a sua autorização.

É sabido que os serviços eletrônicos colocados à disposição dos clientes estão sujeitos a falhas. Desse modo, não havendo dados técnicos que afirmem, com absoluta certeza, que o sistema de segurança do banco é infalível, e sendo os riscos decorrentes de tais falhas inerentes à própria atividade desenvolvida, de rigor reconhecer que a instituição financeira torna-se objetivamente responsável pela reparação dos danos causados pelo vício na prestação de serviço, notadamente em razão da teoria do risco profissional, bem como à luz da Súmula 479 do C. STJ, in verbis: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Tratando-se da responsabilidade do réu, deve ser aplicada a teoria do risco profissional, segundo a qual todos aqueles que se dediquem às atividades comercial e empresarial devem se responsabilizar efetivamente pelos danos causados, só podendo ser afastada tal teoria com a devida comprovação de culpa exclusiva da vítima, de caso fortuito ou força maior, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

"Tratando-se de alegação quanto ao desconhecimento da autoria de transações, é certo que não se pode exigir do consumidor, parte hipossuficiente na relação, a produção de prova negativa, no sentido de que não realizara as despesas" Incumbia, assim, ao réu o ônus de demonstrar, em juízo, a legitimidade das compras contestadas. Todavia, a despeito da apresentação da contestação, desse ônus o réu não se desincumbiu. À luz dos autos, não se desincumbiu o réu quanto ao ônus da

prova referente à compatibilidade das despesas realizadas, convindo salientar a aplicabilidade, no caso, da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade (CC, art. 927, parágrafo único e CDC, art.14, caput). Por outro lado, oportuno salientar que falhas quanto à segurança do cartão magnético com chip não são raras, em decorrência de clonagens desse tipo de produto, pelo que, a mera existência do chip não se revela fator de absoluta e inabalável segurança. Nesse passo, não se ignora que a evolução dos meios tecnológicos possibilitou que os contratos sejam realizados pela internet, smartphone, telemarketing e outras formas eletrônicas, instrumentos que, de um lado facilitam a vida para ambas as partes e de outro, reduzem os gastos das instituições financeiras, com pessoal para atendimento etc..., restando ao direito se adaptar as novas formas de contratação. Contudo, a mera alegação de que as transações foram realizadas por meio de um cartão com chip, não se presta a comprovar a regularidade do débito discutido nos autos, à mingua de elementos hábeis a inferir que se trata, efetivamente, de transação realizada pelo consumidor" (TJSP; Apelação nº1037217-93.2019.8.26.0002; 19ª Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Cláudia Grieco Tabosa Pessoa; j. em 12/05/2020).

Desse modo, é de rigor o acolhimento do pedido inicial para que seja cancelado o empréstimo contratado por meio de fraude na conta da autora, bem como para que a quantia debitada em razão do boleto acima mencionado seja a ela devolvida.

Porém, a devolução deverá ocorrer de forma simples, por não haver comprovada má-fé da parte requerida no caso.

Quanto à indenização por dano moral, haja vista a gravidade da situação evidentemente ocorrida no caso (invasão de aplicativo bancário e realização de transações financeiras sem autorização e consentimento), e os transtornos ocasionados à requerente devido a ela, o pedido merece acolhimento.

Reputo razoável, porém, a fixação de indenização por danos morais no equivalente a R\$ 3000,00 (três mil reais), suficiente para servir de lenitivo à autora sem se traduzir em fonte de ganhos indevidos de sua parte. Ressaltando-se, ainda, o caráter punitivo e pedagógico da indenização, também tendente a estimular que a instituição bancária adote medidas mais eficazes para evitar acontecimentos como o descrito nos autos.

Nesse sentido:

"Ação de indenização por danos morais e materiais - autora que comunicou o furto de seu aparelho celular à autoridade policial - banco requerido que não comprovou que a transferência bancária realizada horas após do furto tenha sido efetuada mediante uso de senha informada pela autora - ausência de prova de que o aplicativo de celular seja guardado com meios de assegurar a identidade de quem tenta realizar transações bancárias à distância - segurança que se espera do referido serviço bancário não evidenciada no caso - responsabilidade civil caracterizada pela falha na prestação dos serviços - danos materiais comprovados - danos morais caracterizados na hipótese - "quantum" adequado - impossibilidade de redução - demanda procedente - sentença mantida - recurso improvido" (TJSP; Apelação Cível 1070931-70.2021.8.26.0100; Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2022; Data de Registro: 28/06/2022).

III. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

A) CONDENAR o requerido a cancelar o empréstimo feito em nome da autora (contrato: 0131605778419156965430712881904184572788), com a consequente devolução (de forma simples) de eventuais quantias debitadas de sua conta a esse título, que será corrigida monetariamente pela tabela prática do Tribunal de Justiça desde a data de

cada pagamento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

B) CONDENAR o requerido a devolver à autora, de forma simples, o valor relativo ao pagamento do boleto indicado às fls. 26 (R\$ 2500,00), corrigido monetariamente pela tabela prática do Tribunal de Justiça desde a data do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e

C) CONDENAR o requerido a pagar à autora o valor de R\$ 3000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

O montante da indenização por dano moral, conforme a orientação predominantemente no Superior Tribunal de Justiça, será corrigido monetariamente a partir desta sentença, segundo os índices do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Os juros, no entanto, incidirão a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Nesse sentido, a contrario sensu:

“CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. O termo inicial de incidência da correção monetária é a data do arbitramento da compensação por danos morais. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso nas hipóteses de responsabilidade extracontratual. Embargos de declaração no recurso especial acolhidos com efeitos aclaratórios” (EDcl no Recurso Especial nº 1054856/RJ (2008/0097307-7), 3ª Turma do STJ, Rel. Nancy Andrighi. j. 02.02.2010, unânime, DJe 12.02.2010).

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95

P.I.C.

Olímpia, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA